

1501021-22.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 53 porções de maconha, com peso de 124,4 gramas, substância esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado adquiriu as porções do tóxico e se dirigiu ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, a fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501021-22.2021.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 4586-8111, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501021-22.2021.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

MAYCON ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, menor de 21 anos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de abril de 2021, por volta das 11h15min, na Rua Antônio Tacildo Vion nº 37, casa 13, Jardim Santa Gertrudes, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 53 porções de maconha, com peso de 124,4 gramas, substância esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado adquiriu as porções do tóxico e se dirigiu ao local

dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, a fim de comercializá-las.

Ocorre que policiais militares receberam delação anônima dando conta do tráfico praticado pelo réu e, de posse de suas características físicas e descrição de suas vestes, dirigiram-se ao local e avistaram Maycon na companhia de outros indivíduos que empreenderam fuga ao avistarem a viatura. O réu, por sua vez, fugiu em direção a uma residência próxima.

Os agentes da autoridade se deslocaram até o imóvel e conversaram com um casal, o qual informou que o filho de um deles residia no local mas desconheciam qualquer envolvimento dele com o tráfico de drogas. Os milicianos tiveram a entrada franqueada na residência e localizaram o acusado, que confessou a traficância e indicou o local onde o tóxico estava guardado.

As drogas foram apreendidas no interior de um guarda-roupas. Também foram localizados um aparelho celular, uma balança de precisão e anotações típicas do comércio espúrio de entorpecentes.

Assim, pela quantidade das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia e analisada a defesa apresentada, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, preliminarmente, alegou ilicitude da prova, vez que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado se deu sem autorização judicial. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Para tanto, sustentou que os depoimentos dos policiais devem ser analisadas com reservas, ante o interesse que tem em justificar sua conduta. Em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; fixação da pena-base no mínimo legal; redução da sanção, no patamar máximo, nos termos do § 4º do artigo 33 do mesmo Diploma Legal; imposição de regime inicial aberto; substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto.

RELATADO.

DECIDO.

Não há falar em nulidade das provas por violação de domicílio ou em ilicitude das provas por derivação, porquanto nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante, ainda mais porque a referida inviolabilidade comporta exceção quando se tratar de hipótese é de flagrante delito ou quando existe um crime em andamento.

Com efeito, "A Constituição não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso de flagrante delito (art. 5º, XI), ocasião em que se poderá efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo, como no caso de "ter em depósito" ou "guardar" substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21/10/76)" (cf. Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10ª ed., Atlas, 2003, nº 241.2, pág. 625). E, in casu, sendo hipótese de crime de tráfico de entorpecentes, sob a modalidade "guardar", o qual, sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante em qualquer momento, presente a situação de flagrância, o que legitimou o ingresso dos policiais militares na residência do réu. Além disso, os genitores do acusado franquearam a entrada dos militares no imóvel.

Assim, como já explicitado, tratando-se de crime permanente e havendo fundadas suspeitas que no local havia comércio ilícito de drogas, tendo em vista a atitude do acusado no momento da chegada dos policiais, que mantinham em sua guarda os entorpecentes, restando extreme de dúvida o estado de flagrância autorizando o ingresso dos agentes públicos no local para efetuar a prisão.

Ensina Guilherme de Souza Nucci, "Em casos de crimes permanentes (aqueles que se prolongam no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., RT, 2008, pág. 530, nº 31).

Outro não é o entendimento do Pretório Excelso, "1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ('denúncia anônima' e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 2. Legitimidade e validade do processo que se originou das investigações baseadas, no primeiro momento, de 'denúncia anônima' dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal" (RHC 86.028/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., DJ de 22/08/08).

E mais, "O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 4. No caso concreto, diante do consentimento válido de seu filho maior de idade para a entrada dos policiais no apartamento e do fato de que a busca domiciliar, a despeito de não amparada em mandado judicial, foi precedida de denúncia anônima de tráfico, de diligências prévias da autoridade policial e da descoberta de drogas em poder de seus filhos, o que caracteriza um quadro de flagrante de crime permanente, não há como se reputar ilegal a apreensão do dinheiro encontrado no apartamento, que constituiu descoberta fortuita válida e legal. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento". (STJ, RMS nº 65.115/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021). Assim também vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça, "(...) 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, verifica-se da peça acusatória, que os policiais militares estavam em patrulhamento pela região e receberam informação de que a paciente estaria vendendo drogas naquela via pública e se deslocaram para o local, surpreendendo-a em frente ao imóvel. A paciente, ao ver os policiais, jogou as drogas na calçada (6 porções de skunk), mas foi detida, admitindo a prática do crime e afirmando, inclusive, que havia mais drogas em sua residência. Assim, os policiais, entraram em sua residência, com sua anuência, e encontraram mais drogas, as quais estavam fracionadas e embaladas individualmente, confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante da paciente. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não

havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial". (HC nº 629.141/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 22/03/2021).

Reconhecida, portanto, a legalidade do ingresso no imóvel, não há que se falar em violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e, por consequência, em ilicitude probatória.

Diante da prova existente verifica-se que a denúncia é procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, do telefone celular e demais objetos, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 18/20 e 126/128), os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica; pelo laudo pericial da balança de precisão (fls. 129/130) e pelos demais documentos acostados aos autos.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu confessou a traficância, dizendo que passou a comercializar drogas para pagar as contas de sua filha, pois estava desempregado. Em Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

No tocante à confissão policial, já decidiu o Tribunal de Justiça, "Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...). Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico" (Apelação Criminal n.º, de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. de 08/01/2009)." (Apelação Criminal nº 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016)

E mais, "É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil". (Apelação Criminal nº 9230875-35.2008.8.26.0000, Rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. de 10/05/2012).

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Pablo Henrique Pipi Cruz, policiais militares que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas e demais objetos em poder do réu. Relataram, ainda, que tiveram a entrada franqueada no imóvel pelos genitores do réu. A mãe do acusado acompanhou a revista efetuada no local.

Como se vê, as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação. Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

Para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes se caracteriza pela prática de condutas variadas, visto se tratar de tipo misto alternativo. Assim, a adequação do comportamento a qualquer um dos núcleos do tipo penal incriminador implica violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante no momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para tipificação do delito.

Assim, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, são suficientes para a consumação do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Não é caso de desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas como pretende a defesa, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da apreensão.

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu MAYCON ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena-base no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista que as circunstâncias judiciais favorecem o réu.

Ausentes circunstâncias agravantes.

A atenuante da menoridade não pode ser considerada, ante o disposto na Súmula 231 do STJ.

Tendo em vista a quantidade de droga apreendida, reduzo a sanção em 2/3 (dois terços), ante o disposto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, resultando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime aberto para início de desconto da pena corporal.

O réu poderá apelar em liberdade, porquanto respondeu solto ao processo.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Assim, fica o réu MAYCON ALEXANDRE DA SILVA, condenado à pena de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituída a corporal nos termos acima propostos.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 20 de maio de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito